

1500138-23.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... em razão da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, policiais civis, no dia 18 de março de 2022, por volta de 15h25min, receberam notícia anônima de que estaria sendo praticado o tráfico de drogas na Estrada Municipal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500138-23.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-23.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076148/2022 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 23711207 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 49/22/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2076148 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISON LUIS PAIXAO FRANCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Gleison Luis Paixão Franco, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 72/73.

O réu foi preso em flagrante. A decisão de fls. 50/52, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Oferecida a denúncia, o réu foi regularmente citado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 90), e apresentou defesa preliminar de fls. 94/95, através da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 08 de julho de 2022, conforme decisão de fls. 99/105.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a parcial procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia, com a condenação do réu tão somente pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal com relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Quanto ao crime de tráfico, alega que o réu, muito embora tenha confessado o delito, declarou-se ser usuário de drogas, aparentava ser morador de rua, e que teria sido ameaçado a praticar o delito, o que permitia o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, o afastamento da causa de aumento previsto no artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

É o relatório.

D E C I D O.

Gleison Luis Paixão Franco, qualificado nos autos, foi denunciado em razão da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, policiais civis, no dia 18 de março de 2022, por volta de 15h25min, receberam notícia anônima de que estaria sendo praticado o tráfico de drogas na Estrada Municipal de Jacutinga, altura do numeral 1500, bairro Parque Universitário, nesta cidade de Rio Claro.

Os policiais foram até o endereço acima apontado, onde montaram breve campana, durante a qual observaram dois indivíduos realizando o tráfico de drogas.

Constatada a situação de flagrante delito, os policiais resolveram abordar a dupla, sendo eles identificados como sendo o réu Gleison, e o adolescente D.J.L.

Em revista pessoal, foram encontrados com o réu 04 porções de cocaína, e 03 porções de mesclado (cocaína misturada ao crack). Com Gleison também foi encontrada a quantia de R\$ 14,00. Já com o adolescente, foram encontradas 14 pedras de crack, 06 porções de mesclado, e a quantia de R\$ 20,00.

Conclui ainda a denúncia afirmando que o réu e o adolescente além da prática do tráfico, também teriam se associado para a prática de tal delito.

Encerrada a instrução, temos que a ação penal é procedente, mas apenas em parte.

Com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, a materialidade veio estampada através do auto de fls. 10/11, que atesta a apreensão, no total, de 05 porções de cocaína, 09 porções de mesclado, de 14 pedras de crack, e da quantia de R\$ 38,00. O laudo de fls. 78/80, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína no tocante às substâncias apreendidas.

A prova da autoria também se mostra segura, e apta a ensejar a condenação.

O acusado, na presença da Autoridade Policial, optou por permanecer em silêncio (fls. 06).

Em juízo, o acusado confessou os fatos. Alegou que é usuário de cocaína desde os vinte anos de idade, e que na época tinha uma dívida de cem reais com traficantes que lhe venderam drogas. O réu disse que foi ameaçado de agressão por tais traficantes, e obrigado por eles a vender drogas na data dos fatos, como forma de livrar-se da dívida. Assim é que o réu disse ter conhecido Daniel na data dos fatos, e que foi Daniel quem levou a droga que passou a ser vendida por ambos naquele ponto. Segundo o réu, Daniel seria a pessoa que iria fiscalizar a venda de entorpecentes naquele dia. Alegou também que desconhecia a real idade de Daniel. Ou seja, o acusado confessou o delito de tráfico, mas alegou que teria sido coagido a vender drogas para quitar uma dívida que tinha com traficantes. Negou apenas que soubesse a verdadeira idade do menor Daniel.

Os policiais civis Jorge e Lucas, ouvido em juízo, relataram que o local em questão já é amplamente conhecido como ponto de tráfico, e que os traficantes que lá agem fazem uso de um ponto de ônibus para a venda de drogas. No dia dos fatos, receberam informações de que novamente o tráfico era praticado no local. Em razão disso, foram até o local, onde montaram uma breve campanha, fazendo uso de uma viatura descaracterizada. Após visualizarem o réu e o menor se revezando na venda de drogas, resolveram abordá-los. Para do entorpecente apreendido foi apreendido com o réu, e o restante com o adolescente Daniel, cuja menoridade foi descoberta por eles somente na Delegacia de Polícia. Os policiais foram categóricos na afirmação de que viram o réu e o adolescente revezando-se no atendimento aos usuários naquele ponto de tráfico. Também disseram terem notado que Daniel pegava a droga com o acusado, o que coloca por terra a afirmação deste último, de que foi o menor quem levou todo o entorpecente até o local. Os policiais disseram ainda que tiraram fotos da venda de drogas realizada pelo réu e pelo menor, fotos estas juntadas à fls. 20/23. Tais fotos servem como prova para a condenação, e corroboram a palavra dos policiais civis ouvidos em juízo. Os policiais, com a devida venia, também foram categóricos quando disseram que viram o réu e o menor juntos na prática do tráfico, e que se revezavam no atendimento dos usuários.

O próprio menor Daniel, ouvido à fls. 04, na presença de sua avó, relatou que vinha praticando o tráfico de drogas há mais ou menos duas semanas, e que pegava a droga que vendia "com meu colega Gleison". Daniel confirmou que, junto com o réu, estava praticando o tráfico na data em questão, e que se encontrava em poder de parte do entorpecente apreendido.

Portanto, além da confissão judicial espontânea, temos que a prova testemunhal não deixa margem a dúvidas acerca da prática do crime de tráfico, impondo-se a condenação.

Convém ressaltar que não consta dos autos que os policiais civis tivessem algum motivo para injustamente acusarem as rés, deixando certa a legitimidade de suas declarações, mesmo porque não desconstituídas por quaisquer outros elementos de convicção, até porque não as conheciam.

A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Por fim, registre-se que eventual condição de usuário de drogas, como alegado, não excluiria a responsabilidade criminal pela prática do tráfico de entorpecentes, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício, tal como teria ocorrido na espécie. Acrescente-se, neste ponto, que o réu, muito embora tenha se declarado usuário, não apresenta qualquer sinal de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade em razão do consumo prolongado de cocaína, e tampouco demonstrou ter praticado o delito mediante coação física ou moral.

Aliás, esse é o entendimento perfilhado pela jurisprudência:

"Ressalte-se que eventual qualidade de usuário do acusado não o torna inapto ao exercício da narcotraficância. Pelo contrário, as condições comumente se conjugam, e uma acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem. Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas autoria e materialidade da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal do réu, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida" (TJSP, Apelação nº 1500188-27.2019.8.26.0559, Rel. Marcelo

Gordo, julg. 20/02/2020).

Por fim, presente a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, visto que, conforme relato seguro dos policiais, o réu praticava o tráfico em concurso com o adolescente Daniel, que foi ouvido na presença de sua representante legal na época, não havendo dúvidas tratar-se de pessoa menor de 18 anos, pouco importando, para o seu reconhecimento, que o réu tivesse ciência de sua idade, por se tratar de causa de aumento de pena de natureza objetiva.

Melhor sorte merece o acusado, no tocante à imputação da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06.

Neste ponto, ressalto que o réu não era conhecido nos meios policiais em razão da prática do tráfico, conforme declararam os policiais ouvidos em juízo. O réu e o adolescente, repita-se, nunca foram vistos juntos naquele local praticando o tráfico, e tampouco existiam suspeitas do envolvimento deles em tal prática delituosa.

Cumprе salientar que o crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, como é cediço, só é evidenciado quando dois ou mais indivíduos se reúnem com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas, de modo estável e permanente.

Desse modo, a condenação pelo delito de associação deve ser lastreada em provas que indiquem de forma isenta de dúvida, que os envolvidos sejam efetivamente, integrantes de um grupo coeso e permanente, criado com o fim específico de fomentar o tráfico de entorpecentes.

Com efeito, a imputação de associação ao tráfico, no presente caso, vem amparada na presunção de que as rés e o adolescente se uniram para o exercício da traficância, de forma autônoma e organizada. Contudo, não existe nos autos qualquer elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes. Nesse ponto, não restou comprovado o ânimo entre o réu e o menor Daniel para formar e organizar suas ações, previamente, no exercício da traficância.

Desta forma, tem-se que a prova dos autos se limita a apreensão dos entorpecentes, e o auto de prisão em flagrante. Ou seja, a prova se limita ao que ocorreu na data dos fatos, e nada mais.

Assim, não há provas suficientes para a condenação das rés pelo delito de associação ao tráfico, tratando-se, assim, de mero concurso eventual entre o acusado e o adolescente.

Segundo preleciona Renato Brasileiro de Lima, "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar" (in "Legislação Criminal Especial Comentada", p. 1037, Ed. JusPODIVM, 5ª edição). Roberto Delmanto ensina que:

"Para a caracterização do crime deste art. 35 não é suficiente uma associação eventual ou acidental entre duas ou mais pessoas (configurada de coautoria ou participação) devendo haver uma associação estável ou permanente" (Leis Penais Especiais Comentadas, Editora Saraiva, 2ª edição atualizada, p. 961).

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 e 42 do Código Penal. O réu, muito embora responda de outra ação penal também por tráfico (fls. 27), é primário e não possui antecedentes, de modo que merece pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, diária no mínimo legal. A quantidade de entorpecente apreendida, que não pode ser considerada expressiva, também não pode justificar a majoração da pena, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Na segunda fase, fixada a pena base no mínimo legal, deixo de considerar a atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ, ainda em vigor.

Na terceira fase, presente a causa de aumento da pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, majoro a pena em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias multa, diária no mínimo legal.

Por ser primário, de bons antecedentes, e não havendo indícios de que integre organização criminosa, o réu faz jus à causa de diminuição da pena prevista no

artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. Contudo, e atento à natureza da droga apreendida, cuja nocividade à saúde humana é notória, entendo que a diminuição da pena deve ser de 1/2, tornando-a definitiva em 02 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 291 dias-multa, diária no mínimo legal.

A respeito do assunto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 anos e 11 meses, em local e horário a serem dirimidos pelo juízo das execuções, além de outros 10 dias-multa, diária no mínimo legal, sem prejuízo da pena pecuniária já fixada. Em caso de descumprimento injustificado da medida, o réu deverá cumprir pena no regime aberto. A respeito da possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, mesmos aos agentes condenados pela prática do tráfico de drogas, filio-me ao entendimento esposado por nossos Tribunais Superiores, que permite tal solução quando se mostra cabível a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (o chamado tráfico privilegiado). Nesse sentido, temos os seguintes julgados:

"STF-0096246) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.

AFASTAMENTO EM RAZÃO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I - A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. II - Ordem concedida, em parte, para restabelecer a pena inicial de três anos, com o redutor original, e determinar que o juízo a quo proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (Habeas Corpus nº 138138/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 29.11.2016, unânime, DJe 13.03.2017);

"STF-0090736) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus

impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840/ES desta Suprema Corte, nos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser apreciadas pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos dos artigos 33 e 44 do Código Penal. 3. Conquanto fixada a pena em quantum adequado ao cumprimento em regime mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a negativa dos benefícios restou motivada exclusivamente pelos dispositivos reputados inconstitucionais por este excelso pretório. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena do paciente e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau. (Habeas Corpus nº 131239/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 19.04.2016, maioria, DJe 27.09.2016);

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu GLEISON LUIS PAIXÃO FRANCO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 anos e 11 meses, na forma acima especificada, bem como ao pagamento de 301 dias-multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, ABSOLVO o acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII,

do Código de Processo Penal.

Em razão da natureza da pena imposta ao réu, poderá ele apelar da presente em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, clausulado.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu em favor da União, devendo a quantia ser revertida ao FUNAD, após o trânsito em julgado, uma vez demonstrada sua origem ilícita.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA